

1500042-67.2021.8.26.0574

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/05/2022

... drogas. Afirmou que já havia relatos de tráfico em relação aos réus. Aduziu que não se recorda do que os réus falaram no momento em que estavam na delegacia sobre suas residências. Contou que é lotado em Avaré e presta serviços somente aqui e tinha notícias de tráfico somente em relação a um deles, mas seu colega, com mais de 30 anos em Avaré, já conhecia também. Respondeu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500042-67.2021.8.26.0574 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500042-67.2021.8.26.0574

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2027241/2021 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 15954091 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 313/21/129 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2027241 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2027241 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 313/21/129 - DISE- DEL.SEC.AVARE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS PAREJA DE OLIVEIRA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

IRONILDO DOS SANTOS PINHEIRO, qualificado a fls. 4 e LUCAS PAREJA DE OLIVEIRA, qualificado a fls. 5, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06, sob a acusação de que na data de 29 de janeiro de 2021, por volta das 17h00min, na Avenida Espanha, 1000, Centro, nesta cidade e Comarca, transportaram e trouxeram consigo, para entrega e consumo de terceiro, 2 (duas) porções de maconha, em forma de "tijolos", embaladas em fita adesiva marrom retorcida e sem embalagem específica, com peso bruto de 992,73g (novecentos e noventa e dois gramas e setenta e três centigramas), substância esta

causadora de dependência física e psicológica, apreendidas a fls. 9/10, constatadas como tal pelo laudo pericial preliminar a fls. 11/13 e confirmadas pelo exame químico toxicológico a fls. 145/147, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de prisão em flagrante delito e demais peças do inquérito policial às fls. 01/153. Convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva às fls. 86/89. Os réus foram notificados (fls. 188 e 198) e, Ironildo através de defensora constituída, e Lucas por meio de defensor dativo, apresentaram defesa prévia (fls. 195/196 e 202/203). Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 20 de julho de 2021 e os réus devidamente citados (fls. 277). Durante a instrução processual foram ouvidas 02 testemunhas de acusação, 02 testemunhas de defesa e os réus interrogados (fls. 383/384 e 428/429).

Em alegações finais, o Ministério Público discorreu sobre toda a prova produzida e, ao final, pugnou pela total procedência da ação, condenando-se os réus nos exatos termos da denúncia (fls. 433/438). A defesa do réu Ironildo postulou pela absolvição com fulcro no artigo 386, V, do CPP. Subsidiariamente, postulou pela absolvição ante a insuficiência de provas (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). Ainda subsidiariamente, requereu seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06. Postulou ainda pela isenção de custas e que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Em caso de eventual condenação, pugnou pela fixação da pena com observância do artigo 42 da Lei 11.343/06 e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06 (fls. 441/449). A defesa do réu Lucas pugnou pela absolvição do acusado com fulcro no artigo 386, inciso VI, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu seja desclassificada a conduta para a prática do art. 28 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, em caso de eventual condenação, requereu a fixação da pena no valor mínimo, considerando-se a atenuante da confissão e aplicação da causa de diminuição do artigo 33, §4º, da lei 11.343/06, do regime inicial para cumprimento de pena o aberto, bem como o direito de recorrer em liberdade (fls. 453/465).

É o breve relatório.

FUNDAMENTO e Decido.

A ação penal é PARCIALMENTE procedente.

A materialidade delitativa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 06/08), no auto de exibição de fls. 09/10, nas fotografias de fls. 14/15, pelo exame de constatação provisória (fls. 11/13), pelo laudo pericial a fls. 145/147, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria, no entanto, entendo que restou incontestada em relação ao uso de droga.

A testemunha de acusação Pedro Carlos de Castro Melenchon, policial militar, em juízo, relatou que abordou os réus porque os viu pela segunda vez passando juntos pela via, e assim que eles notaram a presença policial, jogaram uma sacola plástica em um terreno baldio, e eles foram abordados cerca de 20 metros à frente, e depois foi localizada no terreno a sacola contendo entorpecente. Respondeu que durante a abordagem os réus relataram que tinham pego carona e iam ao médico, porém já os tinham avistado na Avenida Espanha, e ao avistarem os acusados pela segunda vez, notaram que eles estavam muito nervosos, e então abordaram os réus. Acrescentou que o carro dos réus tinha vestígios de drogas. Afirmou que já havia relatos de tráfico em relação aos réus. Aduziu que não se recorda do que os réus falaram no momento em que estavam na delegacia sobre suas residências. Contou que é lotado em Avaré e presta serviços somente aqui e tinha notícias de tráfico somente em relação a um deles, mas seu colega, com mais de 30 anos em Avaré, já conhecia também. Respondeu que não se lembra se Lucas já residiu ou frequenta Avaré.

A testemunha de acusação Sidnei Buran, policial militar, sob o crivo do contraditório, relatou que viram o veículo conduzido pelo réu Lucas e com Ironildo no banco do carona. Asseverou que ambos se comportaram de maneira suspeita, demonstrando nervosismo desde a primeira vez em que foram avistados. Contou que, ao seguir com a viatura o veículo em que os réus estavam, após o condutor tentar uma fuga, o passageiro lançou uma sacola pela janela do carro. Declarou que não se recorda sobre as informações que os réus teriam dado a respeito de onde moravam e nem a respeito de terem dito algo sobre carona para ir ao médico. Disse que

acredita que entre a primeira e a segunda vez que avistaram os réus passaram-se cerca de 3 a 5 minutos, no máximo, e que no cruzamento da Carmen Dias com a Avenida Espanha, eles seguiam no sentido centro, enquanto a viatura policial seguia em sentido ao bairro, e nessa primeira vez os réus adentraram a Avenida Espanha à direita, em direção ao Jardim Europa, enquanto a viatura fez o retorno e foi também pela Avenida Espanha em direção ao Jardim Europa e, na próxima rotatória, cerca de 500 metros à frente, já se depararam com os réus novamente retornando e dirigindo-se ao Jardim Vera Cruz. Respondeu que da primeira vez, chegaram a perder de vista os réus por cerca de um ou dois minutos, mas depois os avistaram novamente.

Acrescentou que o réu Lucas já tinha sido abordado outras vezes e vive nesse meio de traficantes. Narrou que já havia abordado Lucas anteriormente. Relatou que o réu Ironildo não resistiu à abordagem. Aduziu que havia vestígios de maconha no painel do carro. Respondeu que a maconha estava dentro de uma sacola plástica e foi localizada no terreno. Declarou que não viu os réus entregando alguma quantidade de entorpecente para alguém.

A testemunha de defesa do réu Lucas, Paulo Sandro de Almeida Pires, alegou que conhece Lucas de Cerqueira César, e ele mora na mesma cidade. Afirmou que o réu Lucas estava trabalhando com reciclagem e instalação de placas de lojas. Negou que tenha vindo a saber sobre boatos de que Lucas estivesse envolvido com tráfico de drogas.

A testemunha de defesa Gessi Garcia, também arrolado pela defesa do réu Lucas, disse que conhece Lucas porque é seu vizinho e sua mãe mora ao lado de sua casa. Respondeu que ficou sabendo sobre os fatos depois que ele foi preso, mas antes nunca ficou sabendo de nada no sentido de tráfico de drogas por parte dele. Afirmou que o réu Lucas trabalhava com faixas e toldos de propaganda. Relatou que o réu Lucas sempre morou com sua mãe em Cerqueira César.

O réu Ironildo dos Santos Pinheiro, em seu interrogatório judicial, alegou que comprou a droga para dividir com o réu Lucas e cada um pagou R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) por sua parte. Afirmou que é usuário. Disse que tirou só um pedacinho da droga para verificar a consistência dela. Narrou que conheceu Lucas cerca de três ou quatro meses antes e combinou com ele de comprar uma quantidade grande para "ficar tranquilo por dois ou três meses" e não ter que ficar toda hora indo comprar na boca de fumo. Admitiu que olhou pelo retrovisor e jogou a sacola com a droga e não viu onde ela caiu, e que não se apavorou no momento da abordagem. Declarou que realmente ficou com medo e engoliu um cigarro de maconha na hora porque se apavorou. Alegou que ia levar a droga para o local onde fosse trabalhar e lá a consumiria. Afirmou que compraram a droga descendo no Bairro Alto.

O réu Lucas Pareja de Oliveira, em seu interrogatório judicial, disse que comprou a maconha para dividir com o réu Ironildo e que pagaram R\$ 1.000,00 (mil reais) pelo quilo de droga com a qual foram abordados, e que cada um pagou metade. Alegou que é usuário desde os 14 anos de idade e achou por um preço bom em Avaré e acabou vindo para cá para pegar o entorpecente. Disse que ficou com medo da reação de sua avó e por isso não assumiu na delegacia. Negou que Ironildo tenha cortado um pedacinho da droga para experimentar. Afirmou que não viu se Ironildo tirou droga daquele lugar para fumar um cigarro. Disse que não estavam fumando maconha no momento da abordagem, mas já tinham fumado antes. Relatou que conheceu Ironildo um tempo antes de ter sido preso na cidade de Avaré mesmo. Disse que veio para Avaré para tentar comprar maconha. Narrou que encontrou Ironildo na entrada da cidade. Respondeu que tinha combinado com o réu Ironildo que viria para Avaré.

Sendo este o conjunto probatório que se apresenta, a partir da prova oral coligida, percebe-se que os réus confessaram o uso da droga e que não há elementos para indicar, de forma segura e necessária, o comércio da substância apreendida.

Com efeito, verifico que a versão apresentada pelos policiais não encontrou qualquer respaldo com a prova colhida em juízo. Não existem elementos que indicam, com absoluta certeza, que os réus efetivamente estavam comercializando as substâncias.

Ademais, a prova apenas apontou que os policiais localizaram droga de forma esporádica e sem qualquer comprovação do efetivo comércio. A quantidade de entorpecente encontrada e a forma como se encontrava embalada não caracteriza, por

si só, o crime de tráfico, que exigiria, para esse fim, a comprovação de atos inequívocos do comércio ilícito. Em consequência, inviável a condenação pelo delito mais grave, considerando que a quantidade de droga apreendida não extravasa o curial à espécie, não podendo, ainda que o único parâmetro, indicar eventual traficância. Não se pode negar que todo rigor é pouco no combate ao comércio ilegal de drogas, mas a prova, para tanto, deve ser das mais seguras.

É certo que, no caso dos autos, a quantidade de entorpecentes apreendidos poderia levar à presunção da prática do tráfico. Todavia, a presunção não é elemento suficiente para justificar uma condenação, mormente em casos como o dos autos, onde negada a atividade pelos réus e não há outro elemento, objetivo e idôneo, a indicar o tráfico. Não se trata, à evidência, de duvidar ou questionar o depoimento de policiais que, no cumprimento de sua missão, atuam na repressão penal, posto que tão válido como qualquer outro testemunho, como já assentado pacificamente pela doutrina e jurisprudência. Trata-se, isso sim, de exigir a correta formação de culpa, em atenção ao princípio constitucional da presunção de inocência, pois compete ao Estado, para impor sanção, demonstrar de forma cabal a conduta penal do processado.

Dessarte, não se pode descartar a hipótese de que a droga se destinasse ao consumo próprio. Mera suspeita de tráfico não pode convolar-se em certeza, até porque não trazidos aos autos elementos outros, tais como expressiva quantidade de droga, manuscritos contábeis, dentre outros, que indicassem o comércio ilícito, valendo ressaltar que a forma como acondicionado o entorpecente tanto pode indicar o tráfico como a aquisição para uso próprio. Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico ilícito de drogas. Pretendida a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11343/2006; reconhecimento da figura privilegiada; substituição da pena carcerária por restritiva de direitos; abrandamento do regime prisional. - Pleito absolutório inatendível. Comprovadas autoria e materialidade. Cabível a desclassificação para o delito do art. 28. Réu admitiu a posse para consumo próprio. Circunstâncias não demonstram que a destinação das drogas era a comercialização. Policiais não presenciaram atos de mercancia. Pena. Advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do artigo 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06. - Recurso provido, em parte, para desclassificar a conduta para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, no termos do v. Acórdão. Expeça-se, com urgência, alvará de soltura clausulado."

(Apelação Criminal nº 1500249-08.2019.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator(a): Osni Pereira, data de julgamento e publicação: 29/01/2021) (destaquei)

...

"TRÁFICO DE DROGAS -Quadro probatório que não traz a necessária certeza quanto à finalidade mercantil do entorpecente - Posse para uso próprio -Quantidade pequena de droga que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o delito de tráfico - Desclassificação para uso próprio -Admissibilidade -Acerto da decisão desclassificatória para o art. 28, da Lei n. 11.343/06 - Recurso improvido - (voto n. 43702) (Apelação Criminal nº 1500582-14.2020.8.26.0619, da Comarca de Taquaritinga, 16ª Camara de Direito Criminal, Relator(a): Newton Neves, data de julgamento e publicação: 02/02/2021) (destaquei)

De mais a mais, cumpre consignar que, como se sabe, é do balanço do conjunto dos critérios valorativos que se conceitua a diferenciação entre traficante e usuário. E ninguém pode ser condenado por presunção, visto que o reconhecimento da traficância exige prova concludente. Em suma: o conjunto probatório se mostra frágil e duvidoso no tocante ao tráfico, eis que não se comprovou com a certeza indeclinável, fossem os réus mercadores de drogas. Em consequência, não há prova suficiente para imputar aos réus o comércio do entorpecente. Emerge do quadro probatório que a substância apreendida destinava-se ao consumo pessoal dos réus. Por fim, sobre a finalidade do porte do entorpecente, pode-se olvidar, no mínimo, do estabelecimento de um quadro de dúvida, que, em matéria penal, deve ser interpretado em favor dos réus. Sobre a questão, confira-se:

"Tráfico. Desclassificação para uso próprio. Aplicação da máxima do 'in dubio pro reo'. Recurso provido para tal fim. Após o exame das circunstâncias que autorizam o

reconhecimento do tráfico (artigo 37 da Lei 6.368/76) e, após a apreciação das provas, não se pode obter a certeza necessária de que a maconha era destinada, efetivamente, ao comércio ilegal, devendo, assim, prevalecer a solução mais favorável ao réu". (Apelação nº 108.148-3, 3ª Câmara do E. Tribunal de Justiça - Relator: Onei Raphael).

Diante da situação concreta aqui verificada, e não havendo outros indicativos de prova efetiva quanto ao crime de tráfico, o que faz pairar nos autos a dúvida quanto à finalidade da droga apreendida, respeitados doutos entendimentos em sentido contrário, deve prevalecer a desclassificação para o crime de posse para uso próprio. Logo, de rigor a condenação, mas como incursos no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, DESCLASSIFICO para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 a imputação de cometimento do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 feita contra os réus IRONILDO DOS SANTOS PINHEIRO e LUCAS PAREJA DE OLIVEIRA.

Atento a finalidade preventiva e repressiva do artigo 28 da Lei de Drogas, entendo que a medida que mais se adequa para as circunstâncias do caso é a inserida no inc. II do citado artigo, ou seja, prestação de serviços à comunidade. O prazo de 3 (três) meses em tarefa a ser determinada pela Central de Penas e medidas alternativas da Comarca - CPMA para ambos os réus. Após o Trânsito em julgado, façam as comunicações necessárias. Custas na forma da lei.

P.I.C. Avare, 05 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA